

1500010-86.2022.8.26.0587

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ISABELLA CAROLINA MIRANDA RODRIGUES

Comarca: São Sebastião

Foro: Foro de São Sebastião

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião

Foro de São Sebastião

Vara Criminal

Rua Emidio Orselli, 333, Sao Sebastiao - SP - cep 11600-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500010-86.2022.8.26.0587 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500010-86.2022.8.26.0587 - Controle nº 2022/000006

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSENILDO ALMEIDA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Isabella Carolina Miranda Rodrigues

Vistos.

Nos termos da denúncia juntada às fls. 81/82, no dia no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 20:30 horas, na Rua Dionísio Reis, no bairro da Topolândia, nesta cidade e comarca de São Sebastião/SP, JOSENILDO ALMEIDA DA SILVA, qualificado à fl. 02, trazia consigo para fins de tráfico de drogas, 104 (cento e quatro) eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto de 163 gramas (cento e sessenta e três gramas), além de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais) dinheiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 23, auto de constatação preliminar de fl. 24 e laudo pericial definitivo requisitado à fl. 25.

Em razão destes fatos, o réu JOSENILDO ALMEIDA DA SILVA, qualificado à fl. 02, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida (fls. 90/91) e o réu citado (fl. 98). Sobreveio resposta à acusação (fl. 108/109), com manutenção do recebimento da denúncia (fls. 112/116). Houve a realização de audiência de instrução (fls. 149/153 e 189/191), com a oitiva de quatro testemunhas, bem como procedeu-se ao interrogatório dos réus. Em audiência de instrução, foi requerido a liberdade provisória do réu considerando

que ausente o periculum in mora e não mais subsistirem os motivos ensejadores da decretação de sua custódia cautelar, com oposição por parte do parquet. Foi indeferido o pedido pelo Juízo.

Em memoriais por escrito (fls. 193/200) o Ministério Público pugnou pela condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da denúncia, em razão do conjunto probatório, em especial o depoimento dos policiais, ouvidos em juízo.

Ao passo que a Defesa em memoriais por escrito (fls. 201/225) pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente em caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da confissão da segunda fase de dosimetria; requereu na terceira fase a aplicação da atenuante do privilégio, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Requereu, ainda, o direito de acusado recorrer em liberdade, a isenção da pena de multa e a aplicação da detração penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, o pedido formulado na presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa está estampada no boletim de ocorrência (fls. 02/04), laudo de constatação (fl. 24), relatório policial (fls. 74/77), laudo químico toxicológico (fls. 140/142) e prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria é igualmente certa e repousa sobre o réu.

O policial militar Danilo Soares de Carvalho, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que o local da abordagem é conhecido nos meios policiais como sendo local de traficância. Foram em duas viaturas. Ao avistar o réu, este jogou fora uma sacola com cocaína e empreendeu fuga. Ao ser detido, houve a confissão e mostrou que tinha dinheiro em mãos. O réu jogou a sacola em um cercado ao lado do poste de energia. Às reperguntas da Defesa disse que é conjunto habitacional do CDU, tendo pessoas morando próximo. É próximo à escola, quadra de esportes. Não tinha ninguém no momento, por volta de 20:00 horas, aparecendo pessoas posteriormente. O réu mora no conjunto habitacional, mas não soube dizer o apartamento.

O policial militar Anderson Fernando da Silva Neves, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que a equipe de força tática estava em patrulhamento pela Topolândia em local conhecido como ponto de traficância. Viu o réu arremessando as drogas, sendo que o mesmo foi abordado e confessou. Tinha pouco dinheiro no bolso, pois tinha acabado de assumir o turno. Estava traficando devido a falta de empregos em decorrência da pandemia e informou ser reincidente. Foi ele quem pegou a sacola no terreno baldio. Às reperguntas da Defesa disse que o patrulhamento é feito com regularidade por ser local de tráfico de drogas. Há pessoas que residem no local, mas no momento da abordagem não tinha ninguém. Tinha pessoas mais para frente, sendo que não tinha testemunhas do fato. O cerco foi realizado bem na viela.

A testemunha defensiva Bruna Cristina Siegrist Mori, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que não possui antecedentes criminais e que trabalha. Chegou de carro com uma amiga, tinham ido ao mercado. Pediu ajuda ao réu para subir as compras à sua casa. Quando o réu voltou para ir ao parque com a filha, a viatura foi na rua de trás e gritaram ao réu para parar para fazer a abordagem. Disse que não daria tempo para o réu estar traficando, pois estava com a filha e com a sua sacola nas mãos. Os prédios onde ela mora, há traficância, mas não perto de sua casa. É um condomínio onde há tráfico na parte debaixo. Mora na mesma residência há dois anos, vendo truculência policial quase todos os dias com todos os suspeitos. Moradores são abordados indevidamente, mesmo não sendo traficantes, acontecendo com certa frequência. Disse que o réu não traficava. Na hora da abordagem ficou muito nervosa e chamou a irmã para ajudar, mas não conseguiu falar com os policiais. Seus filhos não ficam na parte debaixo sozinhos, por isso nunca viram violência policial. Às reperguntas do Ministério Público disse que não é parente do réu, não sabendo dizer o dia dos fatos, apenas que era dia de

semana. O campo fica perto da sua casa, sendo que o local tem pouca iluminação. Tem um poste de energia perto do local de abordagem. O bloco que mora é o primeiro. Parte das compras estava dentro do carro de sua amiga, outra parte estava no chão. Parte das compras foi feita em Caraguatatuba, outra parte em São Sebastião, O réu trabalhava em uma madeireira e fazia bicos, morando de aluguel.

A testemunha defensiva Marlene Ferreira de Jesus, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, narrou que conhece o réu de vista, pois moram próximos. Conheceu o mesmo quando ele ajudou na construção da escola da Topolândia. No dia dos fatos, estava com seu neto no campo e viu o réu ajudando uma moça a carregar as compras no carro. Viu quando os policiais chegaram e o pessoal começou a avisar que pegaram o réu. Acontece muito tráfico, no local tem muita pessoa de bem. O filho dela é trabalhador, tem um salão de cabeleireiro, e que sempre é abordado. Às reperguntas do Ministério Público disse que não conhece a moça que o réu foi ajudar, mas acha que o nome dela é Bruna. O réu passou da frente da casa dela para a rua, depois foi ajudar a moça. Estava com seu neto no campo quando a moça pediu ajuda para tirar as compras do carro, sendo que ele estava sozinho. O local de traficância é em um campo bem atrás, tendo vielas no local. O réu trabalha em um depósito de construção de madeiras e depois saiu de lá para fazer "bicos". O réu Josenildo Almeida da Silva, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ao ser interrogado, dizendo que possui 35 anos, é solteiro e possui três filhas com 15, 13 e 8 anos, respectivamente. Já foi preso em 2011, mas foi absolvido. Em 2019 os policiais invadiram a casa dele, falando que tinha drogas, mas conseguiu sair na custódia. Trabalhava até o início da pandemia, quando foi demitido. Negou os fatos que ora lhe são imputados na denúncia, dizendo que saiu da sua casa com sua filha, sendo que sua comadre Bruna pediu ajuda com as compras perto de um poste de luz. Disse que subiu com as compras e quando voltou, uma viatura o abordou perto de um poste de luz. O policial saiu do bloco "E" e veio com sacola verde ou azul clara, falando que achou as drogas. O policial perguntou se tinha passagem, sendo que o réu afirmou que sim, mas que era trabalhador e fazia "bico". Alegou que a informação trazida pelos policiais não condiz com a verdade. Às reperguntas do Ministério Público disse que estava com sacola de mercado na mão e que levou na casa da Bruna, que tinha feito duas "viagens". Estava sem sacola na hora da abordagem, que foram os policiais quem trouxeram a sacola. Não conhecia os policiais que o prenderam. Disse que tinha um carro uber do mercado "Semar" lá, que viu tudo, que ficou parado perto da quadra quando a viatura chegou. Disse que era dia 06, mas não sabe o dia da semana. Às reperguntas da Defesa disse que os policiais encontraram uma sacola de drogas, mas não era de sua propriedade. Foi levado para a delegacia para averiguação, pois os policiais acharam que ele estava "pedido".

Pois bem.

Os policiais prestaram depoimentos coesos, em conformidade com as provas dos autos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que os policiais tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação.

Vê-se, pois, que os depoimentos dos policiais ouvidos em juízo confirmaram a prática do delito de tráfico de drogas e estão em consonância com os demais elementos constantes dos autos, não havendo que se falar em falta de provas. Ademais, nada há que pudesse, ainda que superficialmente, colocar em dúvida a lisura do trabalho policial, pelo que o decreto condenatório é solução inevitável. Existe um nexos íntimo entre o ônus de provar e o ônus de alegar, de modo que, estando as partes em condição de igualdade, alegar e não provar é o mesmo que nada alegar. Desta forma, não há qualquer elemento indicativo que pudesse colocar em xeque a dinâmica dos fatos descritos na denúncia.

O réu negou a prática delitativa em juízo, durante seu exercício de autodefesa processual, esta restou isolada, incongruente e inverossímil se confrontada com o restante das provas constantes dos autos, pelo que merece ser afastada.

As testemunhas defensivas também não trouxeram versão consistente com as demais provas dos autos.

Anoto que a quantidade e a natureza da drogas apreendida (104 (cento e quatro) eppendorfs contendo cocaína, com peso bruto de 163 gramas (cento e sessenta e três gramas), além de R\$ 85,00 (oitenta e cinco reais) dinheiro), a forma de acondicionamento das substâncias, já individualizadas e embaladas, prontas para a venda e o consumo, o local onde se deram os fatos e o depoimento coeso e harmonioso dos policiais, evidenciam que eram destinadas ao consumo de terceiros, razão pela qual não há que se falar em insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para o consumo próprio.

Ressalte-se que os policiais disseram que localizaram os entorpecentes que foram lançados pelo réu. Presume-se a lisura dos agentes públicos, pois investidos no cargo para segurança pública. Seria paradoxal o Estado atribuir a tais pessoas a execução de um ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas não aceitar sua palavra na valoração das provas. Tal raciocínio vem sendo aplicado há muito tempo na jurisprudência geral, com ressonância no Supremo Tribunal Federal (HC 87.662-PE, Rel. Min. CARLOS BRITO, j.5.9.06) e no Superior Tribunal de Justiça (REsp. 151.150-SC, Rel. Min. JOSÉ DANTAS, j. 7.4.98).

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecente TESTEMUNHO POLICIAL - VALIDADE - O testemunho dos policiais tem validade como qualquer outro - Depoimentos coerentes - DESCLASSIFICAÇÃO - USO PRÓPRIO - INVIABILIDADE - A quantidade da droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias em que se deu a prisão são fatores que, associados à prova produzida, levam à certeza de que o réu efetivamente se dedicava à mercancia de entorpecentes - PENA - MULTA - QUANTUM - INCONSTITUCIONALIDADE - INOCORRÊNCIA - O preceito secundário do crime de tráfico ilícito de drogas não fere os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena - A quantidade da pena de multa cominada ao tipo penal em questão guarda relação com sua gravidade - Opção de política criminal adotada pelo legislador no combate ao tráfico ilegal de entorpecentes - Julgador que, no momento do cálculo da pena, deverá observar as especificidades do caso concreto - Condenação mantida- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO" (TJSP Ap.n. 0084921-43.2010.8.26.0000 - 15ª Cam. Direito Criminal Rel. AMADO DE FARIA j. 16.12.2010).

Saliento que para a caracterização do crime de tráfico não é necessária a efetiva comercialização das substâncias, que já se consuma pelo fato do agente, nos termos do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06:

"Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Diante de tais circunstâncias, impõe-se a condenação do acusado como incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Resta, enfim, a fixação das penas, porquanto inexistem circunstâncias excludentes da ilicitude ou que isentem os réus de sanção.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, sopesados os critérios estabelecidos nos artigos 59 e 60 do Código Penal e no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, vez que o réu é portador de bons antecedentes (fls. 41/43) e as circunstâncias do delito não desbordam do ordinário.

Na segunda fase, não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. Na terceira fase, verifico ser inaplicável ao presente caso a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista a existência de ação penal em curso por crime idêntico, o que indica a dedicação a atividade criminosa (cf. 00047974920208070001, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021). Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial semiaberto (artigo 33, § 2º e § 3º, do Código Penal), em consonância e harmonia com a dosimetria da pena.

No tocante ao artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de aplicar por ora a detração ou a progressão de regime, pois é matéria de competência da VEC, uma vez que não há substratos fáticos para aferir os requisitos subjetivos necessários. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial do STJ, não há vício na presente sentença ou violação à regra constante no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu (REsp nº 1.843.481-PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021).

Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois ausentes seus requisitos, considerando a quantidade de pena aplicada. Pelos mesmos motivos, sobretudo pela quantidade de pena aplicada, não há que se falar em suspensão condicional da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e, em consequência, condeno o acusado JOSENILDO ALMEIDA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor unitário mínimo legal, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Fixa-se cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante da falta de informações precisas sobre a situação econômica do réu.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, haja vista que inexistem fundamentos para a manutenção de sua custódia cautelar preventiva nestes autos, e o regime de pena imposto é incompatível com a segregação cautelar.

Expeça-se alvará de soltura com urgência.

O réu não apresentou prova da origem lícita dos valores com ele apreendido, razão pela qual decreto sua perda e determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se o necessário.

Oficie-se à delegacia, autorizando a destruição das drogas apreendidas.

Sem prejuízo da expedição do necessário para intimação pessoal do réu, expeça-se o necessário quanto aos valores e às drogas.

Cumpra-se

Condeno o réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anotada gratuidade, a qual resta deferida, nos termos do artigo 13, da Lei 1.060/50.

Transitada em julgado a presente decisão, realizem-se as comunicações de praxe.

P. I. C.

Sao Sebastiao, 25 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA